

1503592-74.2020.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... onde ela morava, e a prática do crime de tráfico de drogas. Sendo o tráfico de drogas crime comissivo e, com base no artigo 13, §2º, do Código Penal, à ausência de elementos a indicarem sua condição de garante e a relevância de sua omissão frente à conduta do adolescente, e tampouco o reconhecimento de algum grau de responsabilidade penal, em razão de omissão imprópria, bem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503592-74.2020.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503592-74.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2211463/2020 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 8777746 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2211463 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Jessica Lane Nunes dos Santos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

JESSICA LANE NUNES DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 02 de setembro de 2019, por volta das 02:40h, na rua José Joaquim da Rocha, nº 5934, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo e guardava 4,45g de "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, em três porções, e 1,39g de "Erythroxylon coca L", ou seja, cocaína, fracionada em doze porções, visando o comércio com terceiro ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da inicial que, na madrugada dos fatos, policiais militares deram ordem de parada a um veículo Ecosport, conduzido por indivíduo identificado como Carlos, e

encontraram duas porções de maconha em seu interior, e que, indagado, o condutor afirmou que havia adquirido o entorpecente de um casal que estava sentado no cruzamento das ruas José Maria Jacinto Rebelo e Martins MMDC.

Ainda segundo consta, já no local indicado, os policiais avistaram Jéssica e o adolescente Gabriel e, realizada a revista, foram encontrados um telefone celular e uma porção de maconha com a ré, bem como seis porções de cocaína com Gabriel. Assim, indagado, o adolescente admitiu que estava vendendo as drogas, e confirmou que tinha mais entorpecentes em sua residência, onde foram encontradas outras quatro porções de cocaína.

A ré apresentou defesa preliminar (págs. 54) e, recebida a denúncia, foi citada (págs. 75).

Durante instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, uma de defesa, e foi interrogada a acusada (págs. 83 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 86/93).

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição da acusada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, aduz pela desclassificação do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para o do artigo 28, ambos da Lei 11.343/06. Em caso de condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06; a fixação do regime inicial aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, por fim, o apelo em liberdade (págs. 97/110).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 12/15), pelo laudo de exame químico toxicológico (págs. 30/32), que evidenciam a existência de substâncias entorpecentes (*Erythroxylon coca* e *Cannabis sativa* L), bem como por toda prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

A ré, em juízo, relatou que estava em sua casa, por volta de 01:30h, e que saiu de sua casa para fumar maconha, pois sua mãe não aceita que fume dentro de casa. Disse que, neste momento, seu namorado lhe avistou e sentou-se com ela para fumarem juntos, tendo sido abordados em seguida. Confirmou que tinha consigo um cigarro de maconha, e que Gabriel trazia quatro papелotes de cocaína, para uso próprio. Aduziu que foram abordados cerca de cinco minutos após se sentarem na esquina e que, após a abordagem, as diligências seguiram para a residência de Gabriel, onde foram encontradas mais três porções de cocaína, também de uso próprio. Explicou que, quando encontrou-se com Gabriel na rua, ele estava indo para a casa de alguns amigos, onde usariam a cocaína. Relatou que ela e Gabriel nunca venderam drogas, e que são somente usuários. Sustentou que, à época, trabalhava em uma banca na rua de sua casa, que trabalhou com registro na CTPS em uma fábrica de máscaras e que, atualmente, tem um novo emprego em uma banca de pesponto. Ao final, relatou que, quando saiu de casa, viu um casal duas quadras acima de onde estava, mas que não sabe se essas pessoas ainda estavam na rua quando foi abordada.

Carlos, ouvido em juízo, relatou que adquiriu as porções de cocaína no bairro Santa

Terezinha, de um casal, mas que não confirma o reconhecimento da ré, pois a rua estava escura e não pôde ver em detalhes a pessoa que lhe vendeu. Contou que nunca havia comprado drogas dessas pessoas no local e que, ao que se lembra, pagou 20 reais pelo entorpecente.

Os policiais militares, ouvidos em juízo, foram coerentes em seus depoimentos, confirmando os fatos conforme a denúncia. Disseram que patrulhavam a Av. Moacir Vieira Coelho, de madrugada, e que, ao avistarem um veículo Ecosport ultrapassar um sinal vermelho, decidiram abordá-lo, ocasião em que encontraram porções de maconha. Informaram que o condutor do veículo lhes disse que havia comprado o entorpecente na rua indicada na denúncia, no bairro Santa Terezinha, sendo que, no local, encontraram Jéssica e Gabriel, que se identificaram como um casal. Afirmaram que, em revista pessoal, foram encontrados com Jéssica um celular – do qual constava queixa de roubo – e uma porção de maconha, e que com o adolescente foi encontrada a cocaína. Contaram que o adolescente assumiu todas as drogas como dele, bem como assumiu que tinha mais drogas em sua residência com o intuito de que não conduzissem a ré à delegacia, pois ela estava grávida. Indagado, o PM Maycon relatou que Carlos apontou especificamente Gabriel como a pessoa que lhe havia vendido as drogas, mas que, em sede policial, a testemunha reconheceu o casal e confirmou que eles lhe forneceram a droga. Disse, ainda, que a ré mora em frente ao local da abordagem e, indagado, aduziu que Carlos explicou que o casal estava sentado, e que, em contato com o rapaz, este lhe forneceu o entorpecente. Ainda, pontuou que não havia mais ninguém pela via pública no momento.

Para além, o PM Johnny acrescentou que, ao que se recorda, foi encontrada maconha com o condutor do Ecosport, e que nunca havia abordado a ré anteriormente, embora Gabriel já fosse conhecido de sua guarnição.

Ao fim, a testemunha de defesa Fabiana, mãe de Gabriel, contou que é sogra da ré, e que estava em casa quando os policiais chegaram em três viaturas, com Gabriel e Jéssica, dizendo que se tratava de um roubo de celular. Confirmou que os policiais revistaram sua residência, e que encontraram quatro porções de cocaína. Asseverou que Jéssica trabalha fazendo máscaras, que tem um filho com Gabriel, e que é usuária de maconha.

Pois bem.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente a ré. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Em análise à prova dos autos, depreende-se que Carlos, quando foi abordado, relatou que havia comprado a cocaína de um rapaz, e que esse indivíduo estava com sua companheira. Todavia, conforme relatado por Carlos, bem como pelos policiais militares, em juízo, não há elementos que comprovem a autoria, ou mesmo participação, da ré na prática ilícita. Isto porque, ao que tudo indica, foi Gabriel quem vendeu a cocaína, não somente pelos relatos prestados, mas ainda pelo fato de que todas as porções de cocaína estavam com ele, inclusive em sua residência, enquanto a acusada somente tinha consigo o cigarro de maconha.

E, no ponto, destaco que, embora Jéssica afirme que acredita ter visto um outro casal ruas acima, e que seu namorado havia acabado de chegar ao local, na tentativa de levar a crer que não foi ele quem vendeu o entorpecente, não convence, não somente pelo fato de Carlos ter apontado onde havia comprado a droga, e de os

policiais militares terem confirmado que já conheciam Gabriel de abordagens anteriores, mas ainda pela extrema coincidência que se exigiria, de que houvesse um outro casal, no mesmo horário e em local semelhante, com cocaína acondicionada para venda. Assim, a despeito da quantidade de cocaína apreendida, a forma em que estava fracionada a droga, em pequenas porções, bem como diante das demais porções apreendidas na residência de Gabriel, demonstram que foi ele quem vendeu a droga para Carlos.

Tudo posto, ressalto que não há relação de causalidade entre a atitude da vítima, que fumava maconha com seu namorado defronte à residência onde ela morava, e a prática do crime de tráfico de drogas. Sendo o tráfico de drogas crime comissivo e, com base no artigo 13, §2º, do Código Penal, à ausência de elementos a indicarem sua condição de garante e a relevância de sua omissão frente à conduta do adolescente, e tampouco o reconhecimento de algum grau de responsabilidade penal, em razão de omissão imprópria, bem como pelo conhecimento de que a simples convivência não é punível, não há de se falar na condenação da ré pelo crime que lhe é imputado. Neste sentido, ensina a doutrina:

“11-F. Convivência: trata-se da participação por omissão, quando o agente não tem o dever de evitar o resultado, tampouco aderiu à vontade criminosa do autor. Não é punível pela lei brasileira, pois inexistente um dever legal de agir, mas somente um dever moral. Se alguém, visualizando a ocorrência de um delito, podendo intervir para impedir o resultado, não o faz, torna-se conivente (falha moral). É o chamado concurso absolutamente negativo.” (NUCCI, Guilherme. Código Penal Comentado. 18 ed. 2018).

“Ocorre quando o sujeito, sem ter o dever jurídico de agir, omite-se durante a execução do crime, quando tinha condições de impedi-lo.

A convivência não se insere no nexo causal, como forma de participação, não sendo punida, salvo se constituir delito autônomo. Assim, a tão só ciência de que outrem está para cometer ou comete um crime, sem a existência do dever jurídico de agir (CP, art. 13, § 2º), não configura participação por omissão.

Na lição de Aníbal Bruno, “a simples presença no ato de consumação ou a não denúncia à autoridade competente de um fato delituoso de que se tem conhecimento não pode constituir participação punível. É a chamada convivência. (Direito penal, cit., t. 2, p. 278.)” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial: dos crimes contra os costumes a dos crimes contra a administração pública. V. 3 – São Paulo: Saraiva, 2004).

Não obstante, os policiais relataram, de maneira congruente e coesa, em fase policial e em juízo, que Jéssica tinha consigo uma porção de maconha, fato este reiteradamente confirmado por ela, ao afirmar que fumava um cigarro de maconha quando foi abordada. Destarte, destaco que a ré praticou a infração capitulada no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. E, como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP – Ap. Crim 218.429-3/3 – Rel. Des. Néelson Fonseca – 6ª C. – J. 17.4.97 – Um; e TJ-MG – APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

E, assim, impõe-se a regra da emendatio libelli, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, sendo certo que “se a errônea qualificação jurídica da infração penal não compromete a descrição do fato, sua correção não acarretará mácula ao processo. O imprescindível é a narrativa do fato com todas as suas circunstâncias” (TJSP – Apelação 0008.616-96.2009.8.26.0050 – 3ª Câmara de Direito Criminal, rel. Amado de Faria, 02.07.2013, v.u.).

Vale consignar que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a conduta do agente, sendo irrelevante a quantidade de droga a ser apreendida, bem como desnecessária a efetiva lesão, pois o tipo penal visa a proteger a saúde pública e a sociedade de modo geral. Nesse aspecto STJ - AgRg no REsp 1581573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 09/11/2016; STJ - AgRg no REsp 1576825/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016; e STJ - AgRg no AREsp 620.033/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015.

Colaciono também:

(...) O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (...) (STJ - RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

A nova redação do crime de porte de entorpecentes, prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, apenas afastou a incidência de pena privativa de liberdade ao acusado, despenalizando a conduta, mas mantendo hígida a figura típica. Assim STJ - HC 292.292/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014; STJ - REsp 1544041/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 04/12/2015; e STJ - HC 299.988/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 17/09/2015. Portanto, ressalto que não há que se falar em atipicidade de conduta.

Em relação à constitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário 635659, sendo a norma válida e eficaz, de modo que a conduta de portar drogas para uso próprio continua sendo típica, e, de regra, ilícita.

Desse modo, não restam dúvidas de que a acusada praticou o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, conduta tipificada no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06 e, de rigor, pois, na ausência de excludentes, o reconhecimento de sua responsabilidade penal.

Passo à dosimetria da pena.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, bem como do artigo 59 do Código Penal, verifico que não são desfavoráveis à ré. Portanto, verifico que a reprimenda que melhor se ajuda ao caso é a à pena advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, medida necessária e suficiente, na espécie, para a reprovação, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei de Tóxicos.

Considerando a natureza da pena aplicada, eventual recurso poderá ser interposto em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar JESSICA LANE NUNES DOS SANTOS, qualificada nos autos,

como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, facultado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, autorizo a destruição da droga apreendida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA